



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

מבחן הסמכה - חלק ראשון - מטלת כתיבה – קיץ 2021

ענה על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניך.

שאלה מס' 1:

גב' ליבי למד, ת"ז 011111111 מכפר אז"ר 54, פונה אליך לייעוץ משפטי. ליבי מספרת לך כי היא פעילה סביבתית למען פרחי הבר בישראל. מדי שבוע היא וחבריה מפגינים בעד הגנה על פרחי הבר. לאחרונה, בשל משבר הקורונה, הוסמך שר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: השר), במסגרת החוק למניעת תפוצת נגיף הקורונה בגידולים חקלאיים, התש"ף-2020 (להלן: החוק), להתקין תקנות הנוגעות למניעת הפצתו של נגיף הקורונה בהקשר של תוצרת חקלאית. מכוח החוק התקין השר את תקנות מניעת קורונה בחקלאות, התש"ף-2020 (להלן: התקנות). אף שהחוק לא הסמך את השר להגביל השתתפות בהפגנות, נקבע בתקנה 5 לתקנות כי אין לקיים הפגנות שעניין נוגע לצמחים או לבעלי חיים.

ליבי טוענת כי היא אינה מבינה את האיסור להפגין. לטענתה היא מודעת להגבלות הקורונה, אך היא מתחייבת כי בהפגנות יישמר מרחק של 2 מטרים בין המפגינים והם יעטו מסכות. היא סבורה כי ההפגנות שהיא מקיימת אינן מפרות כל חוק ואינן יוצרות סיכון להפצת הנגיף. היא חשה כי זכותה הבסיסית להפגין נלקחת ממנה, ובכלל זה החופש לבטא את דעותיה ולבטא את מאבקה הצודק להגנת פרחי הבר.

ליבי ציינה בפניך כי פנתה 5 פעמים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לפני פנייתה אליך, ובקשותיה נדחו על הסף. ליבי הציגה בפניך את הפניות והתשובות להן.

עוד טוענת ליבי כי בידיה התכתבויות המעידות על כך שהתקנות התקבלו בעקבות לחץ מקדים שהפעילו ארגוני חקלאים על השר באמצעות חברי מרכז מפלגתו. לחקלאים עניין בהסרת ההגנות על פרחי הבר, שכן הם מעוניינים לחסוך בעלויות העישוב והריסוס שנועדו למנוע צמיחת פרחי בר בשטחים שהם מעבדים.

סייע לליבי לנקוט בהליך המשפטי המתאים ונסח עבורה את המסמך המשפטי המתאים במקרה זה.

את תשובתך יש לבסס מתוך המקורות המצורפים ולהסתמך על הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי מקורות אלה משקפים את המצב המשפטי העדכני.

יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את המסמך בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

1. מתוך בג"ץ 6536/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל:

"...ואולם, כללי הפרשנות התכליתית שעליהם עמדנו לעיל משמיעים לנו, כאמור, כי התכלית האובייקטיבית המונחת ביסוד כל דבר חקיקה התקף בישראל, היא שמירה על עקרונות היסוד של השיטה ובכללם - ההגנה על חירות הביטוי וההפגנה. בחירויות אלה אין לפגוע אלא בהתקיים וודאות קרובה לפגיעה רצינית וקשה בשלום הציבור ותכלית אובייקטיבית זו מחייבת פרשנות מצמצמת של המונחים 'מדיני' ו'פוליטי', ככל שהדבר נוגע לדרישה לקבלת רישיון להפגנות".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

2. מתוך בגץ 4790/14 יהדות התורה נ' השר לשירותי דת:

אמת המידה הבסיסית לתקפותה של חקיקת משנה עולה מדבריו של המחוקק הראשי, שהרי "בלעדי הענקת הסמכות על-פי דברו של המחוקק הראשי אין למחוקק המשנה ולא כלום". על חקיקת משנה להתיישב עם הוראות החוק המסמיך ולנבוע ממנו. חקיקת משנה החורגת מהוראות החוק המסמיך אינה יכולה לעמוד. בצד זאת, על חקיקת משנה חלים גם הכללים הרגילים הנוהגים ביחס למעשה המינהלי, ובכלל זה האיסור לשקול שיקולים זרים, דרישות הסבירות ודרישת המידתיות.

3. מתוך בגץ 415/19 לוי נ' שר הפנים:

"האיסור על ניגוד עניינים נובע מהחובה החלה על הרשות לפעול בהגינות ובתום לב ובהתאם לכללי הצדק הטבעי, ולשקול שיקולים ענייניים בלבד, היינו - שיקולים הנובעים מהתפקיד ונדרשים למילוי, להבדיל משיקולים אישיים ושיקולים זרים אחרים. האיסור על ניגוד עניינים דרוש גם כדי להבטיח את אמון הציבור בשירות הציבורי".

4. מתוך בגץ 7190/05 לובל נ' ממשלת ישראל:

"בית משפט זה אינו נוהג לעשות שימוש בסמכותו כל עוד לא מיצה העותר סעד חלופי יעיל שעומד לו על פי דין. כך, לא פעם נפסק כי אי מיצוי הליכים על ידי פניה לרשות המוסמכת קודם הגשת עתירה מצדיקים דחייה על הסף".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה מספר 2:

יעל פרסמה הודעה בעמוד הפייסבוק "עובדים בצל הקורונה". היא כותבת שם שגם אחרי פתיחתו של המשק המעסיק שלה דורש ממנה, כמו מעובדים נוספים, לעבור לעבוד מהבית באופן מלא. היא כותבת שם: "איך בדיוק המעסיק שלי רוצה שזה יתבצע? מה מותר לו? אין התייחסות לשום דבר כזה בחוזה שלי, אין לי את האפשרות להתארגן על סביבת עבודה נורמלית מהבית ואני די בטוחה שזה גם יעלה לי לא מעט".

בתגובות לפוסט של יעל אתה מעלה תגובה משלך וכותב: "אכן מדובר בסוגיה מורכבת שמצריכה בחינה של משפט העבודה, האם זה אפשרי וגם מה המשמעות הכלכלית של מעבר לעבודה מהבית ועל מי לשאת בעלויותיו". התגובה יוצאת מחשבון הפייסבוק העסקי שלך ומצוין בו שאתה עורך דין.

יעל רואה את התגובה ופונה אליך בפרטי. היא כותבת לך: "אני מבינה את המורכבות, נראה לי, אבל למה שזה יהיה על חשבוני? למה המעסיק יכול לקבוע לי, זה לא מה שהסכמתי לו!" היא מבקשת ממך לסייע לה ולחברותיה לעבודה ולהכין להן חוות דעת משפטית בנושא, ומרחיבה: "אין לנו גם אפשרות לבקש באופן חריג להגיע למשרד. המעסיק החליט שלא להאריך את השכירות על המשרדים, אז גם אם נרצה כבר אין לי ולחברותיי אפשרות להגיע למשרד, כש-5 קומות נותרה רק קומה אחת. אנחנו ממש חוששות, עובדות באותו מקום מעל 6 שנים ולא רוצות להתפטר, בטח לא במצב השוק של היום".

במציאות החדשה שנוצרה בעקבות משבר הקורונה נאלצו רבים לעבור למתכונת של עבודה מהבית. כתוצאה מכך ניתן להניח שהמשבר הנוכחי ידחוף יותר ויותר מעסיקים לבחון חלופות שונות למודל ההעסקה הקלאסי גם בחלוף המשבר, בין כדרך לחיסכון בעלויות ובין מתוך הכרה בתועלות העולות על האתגרים הנלווים לעבודה מהבית.

על בסיס כל האמור יש לנסח חוות דעת משפטית בעניינה של העובדת. יש לפרט את עובדות המקרה הרלוונטיות ולבצע את הניתוח המשפטי לעניין החזר ההוצאות.

יש להתבסס אך ורק על הנתון בשאלה ועל פסקי הדין המובאים להלן, בנוסף לידע המושגי שלכם במשפטים. הניחו כי פסקי הדין המצורפים משקפים את המצב המשפטי העדכני. תשובתכם מוגבלת לשני עמודים.

1. מתוך בג"ץ 239/83 מילפלדר נ' בית הדין הארצי לעבודה:

"בהעדר אחת מהנסיבות הללו, יחול העיקרון הכללי, לפיו צד לחוזה אינו רשאי ואינו יכול לשנות באופן חד-צדדי תניה מתניותיו. עמד על כך בית המשפט העליון... 'שינוי בתנאי עבודה או בזכויות וחובות אישיות קיימות, פירושו החלפת הקיים בחדש; ומסתבר כי זה יכול לבוא רק כתוצאה מהסכמה הדדית'. ..חוזה עבודה אישי הוא גזע...במשך חייו, עשויים לצמוח לו ענפים חדשים ועלים חדשים....וכל זאת במסגרתו של הגזע הקיים. אך תנאי יסודי הוא, כי התחדשות זו תבוא בדרך ההסכמה".

2. מתוך ע"ע (ארצי) 350/03 מדינת ישראל-משרד העבודה והרווחה – אברהם גרינשפן:

"אלה אמות המידה לקביעת הפיצוי על הפרת חוזה העבודה – היינו יש לקבוע סכום אשר יפצה המשיבים על הצורך לשנות דרכי חיים שהיו רגילים להם ושהתבססו על תנאי בחוזה העבודה האישי שלהם...".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

3. מתוך ע"ע (ארצי) 111/11 כהן – חברה בע"מ:

"ייחסי עבודה מושתתים מעצם מהותם על הסכם בין מתקשרים שאינם שווים במעמדם, בהם העובד נמצא בעמדת חולשה מובנית אל מול המעסיק אשר בידיו הכוח לקבל את העובד לעבודה, לקבוע תנאי העסקתו ולפטרו. כאשר בהתאם, נדרש המחוקק לחוקי המגן אשר נועדו לאזן מערכת יחסים בלתי שוויונית זו".

4. ע"א 10582/02 ישראל בן אבן נ' דלתות חמדיה:

"יזכר כי כתוצאה מסעיף 61(ב) הפך חוק החוזים (חלק כללי) לחוק חיובים כללי, 'מצודתו פרושה... על כלל המערכת המשפטית בישראל... 'דין החוזים הפך, באמצעות סעיף 61(ב) לחוק החוזים, לעוגן לעקרון תום הלב במשפט הישראלי כולו... דוקטרינה אשר 'מלוא כל הארץ כבודיה'".

מתוך חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973:

39. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

61. (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

(ב) הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין בשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.

סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979:

1. (א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה.

(ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת.

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי הינה לשימוש פנימי ואינה מוצגת לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

ב ה צ ל ח ה !